

1502198-90.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO DIAS ALVES BATISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual DIOGO DIAS ALVES BATISTA, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502198-90.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502198-90.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO DIAS ALVES BATISTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual DIOGO DIAS ALVES BATISTA, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Narra a denúncia (fls. 56/57) que, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 02h10min, na Rua República do Líbano, n.º 100, Centro, nesta cidade e comarca de Osasco, DIOGO DIAS ALVES BATISTA, qualificado à fl. 07, com fotografia à fl. 18, trazia consigo drogas, para entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 22 (vinte e duas) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 3,1 gramas, e 06 (seis) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 8,9

gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 14, fotografias às fls. 16/17, laudo de constatação às fls. 34/36 e laudo de exame químicotoxicológico a ser oportunamente acostado aos autos.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando se depararam com o denunciado, ao lado de outra pessoa, mostrando algo nas mãos e um volume na cintura. Diante de tal conduta suspeita, os agentes da lei decidiram abordá-los, porém, ao notarem a presença policial, ambos empreenderam fuga, cada qual para um lado. O denunciado acabou detido e, em revista pessoal, localizaram, em seu poder, mais especificamente na pochete que trazia em sua cintura, 22 (vinte e duas) porções de crack e 06 (seis) porções de maconha, além da quantia de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais) em dinheiro trocado. O outro indivíduo que o acompanhava logrou se evadir. Indagado sobre os fatos, o denunciado confessou informalmente que estava vendendo entorpecentes.

Pela significativa quantidade/variedade de entorpecentes apreendidos, associada às circunstâncias de sua apreensão, incluindo a confissão informal do denunciado, é certo que as drogas se destinavam a entrega ao consumo de terceiros.

Auto de prisão em flagrante às fls. 01.

Auto de exibição e apreensão às fls. 14.

Fotografia dos entorpecentes e demais objetos apreendidos às fls. 16/17 e 19.

Folha de antecedentes e certidões de distribuição criminal em nome do acusado às fls. 25/33.

Laudo químico-toxicológico às fls. 34/36 e 44/46. Laudo químico-toxicológico definitivo às fls. 79/81.

Em sede de audiência de custódia (fls. 37/38 e 43), a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva. Mandado de prisão cumprido às fls. 61/62.

Em decisão de fls. 65/70, procedeu-se à conversão do rito especial previsto na Lei 11.343/06 para o rito ordinário do Código de Processo Penal e a denúncia foi integralmente recebida.

Citado às fls. 85, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 89/90). Não foram suscitadas questões preliminares e pugnou-se por expor as considerações de mérito ao final da instrução.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 92/93, mesma oportunidade em que foi designada audiência de presencial instrução, debates e julgamento para o dia 22.11.2022, às 13h30.

O acusado se encontra preso desde 14.09.2022. Decisão de fls. 37/38 homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva. Mandado de prisão cumprido às fls. 61/62.

Em debates, foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu, ao final, interrogado.

Em debates, a Acusação pediu a procedência nos termos da inicial.

Em debates a Defesa apontou inconsistências na prova e pediu a absolvição por falta de provas, eis que há dúvida quem seria o vendedor e quem o comprador. Em caso de condenação, pede a desclassificação para o art. 28. Pena base e regime diverso do

fechado.

É relatório.

Fundamento e decido

A - Preliminarmente, anoto que não se verifica ilegalidade na conduta dos policiais a ponto de tornar a prova ilícita. A abordagem policial não foi tão somente baseada em "tirocínio" dos agentes públicos ou somente em "nervosismo", o que denotaria o mais puro subjetivismo, mas sim em comportamento efetivo, vale dizer, porque os policiais avistaram o réu, com um volume na cintura, com outra pessoa, sendo que ele teria repassado algo. Ao ver a viatura ambos passaram a caminhar. Quando perceberam que seriam abordados ambos correram cada um para um lado, o que despertou a atitude de perseguição. Assim, cumprido o standard do art. 244 do CPP para atuação policial.

B - Do mérito

B.1 - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consto a que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06) tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (fls. 02/04), auto de exibição e apreensão (fls. 14), fotografias das drogas, dinheiro e pochete (fls. 16/19) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 79/81).

Quanto a imputação de autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput"), eis que o réu, de fato, considerando a forma de acondicionamento, variedade e quantidade, ainda que não expressiva, trazia entorpecentes destinado a terceiras pessoas.

O réu ouvido em juízo confirmou que estava com a droga, bem como o dinheiro na pochete. Contudo, negou a destinação do entorpecente, uma vez que afirmou que teve uma recaída, trabalhou a semana inteira e comprovou a droga para seu próprio consumo.

A versão do réu de que as drogas não seriam destinadas a terceiras pessoas, mas sim para seu consumo, não encontra ressonância no conjunto probatório.

As provas produzidas em juízo pelo Ministério Público, corroboradas pelos elementos materiais (boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial), permitem a superação da presunção constitucional para além de qualquer dúvida razoável.

Os policiais, em resumo, e essencialmente, relatam que estavam em patrulhamento pela praça Antônio Menk. Avistaram duas pessoas, dentre elas o réu. Uma pessoa passava algo para a outra e estava com um volume na cintura, o que chamou a atenção. Ao verem a viatura passaram a caminhar no mesmo sentido. Entretanto, ao perceberem que seriam abordados, com a abertura da porta da viatura, ambos

correram, cada qual para um lado. Focaram na pessoa que estava com o volume na cintura. Esta pessoa foi detida na rua República do Líbano, após uns 2 minutos de perseguição. Em revista pessoal foi localizada a pochete, havendo no seu interior drogas ("crack" e "maconha") e dinheiro (em notas diversas). A outra pessoa não foi localizada.

Inicialmente, na fase de valoração, não há porquê se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é por que a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas.

As testemunhas policiais não discrepam em suas versões, possuem linearidade e, também, reciprocamente são coerentes e, acima de tudo, estão consentâneas com as demais provas produzidas, especialmente as materiais.

Nesse sentido: (...) 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. (...) (STJ - 5ª Turma - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.936.393 - RJ - Rel. Min. RIBEIRO DANTAS - j. 25.10.2022).

Portanto, a premissa fática do Ministério Público, qual seja, no dia 14 de setembro de 2022, por volta das 02h10min, na Rua República do Líbano, n.º 100, Centro, nesta cidade e comarca de Osasco, DIOGO DIAS ALVES BATISTA, qualificado à fl. 07, com fotografia à fl. 18, trazia consigo drogas, para entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 22 (vinte e duas) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 3,1 gramas, e 06 (seis) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 8,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, está devidamente comprovada nos autos.

As provas demonstram, para além de qualquer dúvida, de fato, a conduta de trazer consigo entorpecente, sem autorização legal e regulamentar, de forma consciente, e que as drogas seriam para consumo de terceiros, tendo em vista a forma como acondicionadas (porções individuais), a quantidade, ainda que não expressiva, além da quantia em dinheiro apreendida em notas de pequeno valor (fls. 19) e as condições nas quais se desenvolveu a ação, ou seja, o réu ao ver os policiais tentou se evadir, estando de posse de uma pochete (objeto comumente utilizado no tráfico de drogas). Não há dúvidas, portanto, que a droga estava com o réu (fato inclusive admitido) e se destinava ao comércio espúrio. Em que pese haver pequenas divergências nos depoimentos, estes pontos não são capazes de infirmar a prova produzida e afastar a responsabilidade penal.

Além do mais, ainda que não seja prova direta, mas circunstancial, é de se salientar que os policiais mencionaram que houve uma interação entre as pessoas avistadas, na qual a pessoa que estava com o volume na cintura, repassou algo a outra pessoa.

Portanto, superado o postulado da presunção de inocência, legítima é a condenação com consequente imposição de pena, eis que reconhecida a responsabilidade penal, não havendo falar em desclassificação.

C - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena em relação a Leonardo:

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/06 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, em especial a quantidade e as espécies de drogas apreendidas, nada indicando excepcionalidade, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência, aumento a pena em 1/6 o que perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias multa.

Na terceira fase, diante da reincidência, não há falar na causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Pela natureza do crime e pela quantidade da pena, o réu não faz jus a substituição por restritiva de direitos.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime inicial fechado em razão do reconhecimento da reincidência, conforme art. 33, §2º, "b" do Código Penal.

O réu está preso desde o dia 14.09.2022, portanto, pouco mais de dois meses. Anoto, antes de qualquer consideração, que comungo da posição de que a detração deve se dar relativamente ao crime pelo qual o réu está preso e considerações de mérito ou de somatória de pena para fins de progressão devem ser aferidas pela Vara das Execuções Criminais. Nesse sentido: "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 2. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. 3. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp 1834978 / SP - 5ª Turma - Min. RIBEIRO DANTAS - j. 04/05/2021 - DJe 10/05/2021)

Destarte, mesmo detraindo o tempo de prisão o regime continuará sendo o fechado eis que fixado em razão da reincidência.

D- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e: CONDENO DIOGO DIAS ALVES BATISTA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa no valor mínimo, com atualização desde o trânsito em julgado, por infração ao art. 33 "caput" da Lei 11.343/06.

E - Demais deliberações

O réu não poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória, não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento

das razões de sua prisão. Ademais, esta medida se impõe para se garantir o cumprimento da reprimenda penal imposta em regime fechado e para se preservar a ordem pública tendo em conta a reincidência - em tráfico - anotada.

Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra recolhido.

Interposto recurso, expeça-se guia de execução provisória da pena privativa de liberdade, de acordo com o artigo 674 do Código de Processo Penal, o artigo 105 da Lei de Execução Penal e o enunciado da Súmula 716 do E. Supremo Tribunal Federal.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

i) Expeça-se guia de recolhimento definitiva ou as peças necessárias para eventual complementação da guia provisória, encaminhando-se, em seguida, à Vara das Execuções Criminais competente.

ii) Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

iii) Determino a destruição do objeto apreendido. Oficie-se.

iv) quanto ao dinheiro, sendo decorrente da venda de drogas, determino a perda em favor do Estado. Oficie-se.

v) No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 22 de novembro de 2022.